

1501502-08.2021.8.26.0407

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... com relação ao crime de associação para o tráfico e, com relação ao crime de tráfico de drogas, requereu aplicação da atenuante da confissão (fls. 373/374).

A Defesa de Marcos pugnou pela absolvição, subsidiariamente, caso haja condenação, que seja reconhecido o tráfico privilegiado (fls. 363/372).

A Defesa de João pugnou pela absolvição, subsidiariamente, caso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1501502-08.2021.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 21 de fevereiro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501502-08.2021.8.26.0407

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HIGOR DE MATTOS FERNANDES e outros

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de HIGOR DE MATTOS FERNANDES, MARCOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS e JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA por supostamente terem praticados os fatos descritos na denúncia:

"Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 17:00 horas, na rua Piauí, nº 360, Parapuã, nesta Comarca, HIGOR DE MATTOS FERNANDES, MARCOS ANDRÉS DA SILVA DOS SANTOS e JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA, respectivamente qualificados a fls. 05, 06 e 07, associaram-se para o fim de praticar o delito de tráfico de entorpecente, visto que, em unidade de desígnios, em concurso, guardavam e tinham em depósito, 09 (nove) porções de "cocaína", com peso de 7 gramas, e 25 (vinte e cinco) porções de "cocaína", em forma de "crack", com peso de 15,93 gramas, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 192/198.

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, dando cumprimento ao mandado de busca domiciliar expedido no processo digital nº 11501233-66.2021.8.26.0407, policiais civis compareceram à residência do denunciado HIGOR, localizada no endereço mencionado, e surpreenderam os denunciados na posse das drogas citadas, preparando-

as para a mercantilização, ou seja, fracionando e embalando o entorpecente, utilizando-se para tanto de um prato, colher, balança de precisão e diversos "saquinhos" plásticos.

Assim, durante a diligência, os agentes estatais localizaram 8 (oito) porções de cocaína fracionadas e uma porção ainda a granel, bem como outras 25 porções de "crack", todas já fracionadas para comercialização.

Em poder do denunciado HIGOR, especificamente em sua carteira, foi localizada e apreendida a quantia de R\$ 110,00. Na posse do denunciado MARCOS ADNRÉ, em sua carteira, foi localizada e apreendida a quantia de R\$ 200,00.

Então, os denunciados foram algemados e conduzidos à Unidade Policial para as providências pertinentes, juntamente com os entorpecentes, o dinheiro e os artefatos que estavam sendo utilizados para o preparo das drogas e sua comercialização.

Diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas, além da forma como estavam embaladas, o dinheiro, a balança de precisão e demais objetos encontrados no local dos fatos, utilizados para o preparo do entorpecente para a comercialização, considerando, ainda, as informações de que os denunciados estavam traficando drogas, tanto que a diligência se deu para cumprimento de mandado de busca domiciliar justificada nestas informações, bem como o desenrolar dos fatos acima descritos, não se olvidando da condição pessoal dos denunciados, fica evidente que estavam associados visando o tráfico de drogas, e os entorpecentes apreendidos tinham a mercancia como destino."

Foi apresentada defesa prévia pelos réus (fls. 256/264; 265/272 e 273).

A denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fl. 279).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado os réus (fls. 344)

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 345/362).

A Defesa de Higor pugnou pela absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico e, com relação ao crime de tráfico de drogas, requereu aplicação da atenuante da confissão (fls. 373/374).

A Defesa de Marcos pugnou pela absolvição, subsidiariamente, caso haja condenação, que seja reconhecido o tráfico privilegiado (fls. 363/372).

A Defesa de João pugnou pela absolvição, subsidiariamente, caso haja condenação, que seja reconhecido o tráfico privilegiado (fls. 373/374).

Vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2); termo de ocorrência (fls. 3/11); auto de exibição e apreensão (págs. 12/13); imagens do local do crime e dos objetos apreendidos (fls. 24/25); laudo pericial (fls. 192/198); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva será analisada com relação a cada crime.

A testemunha CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA, policial civil, em seu depoimento judicial, relatou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Higor, os réus foram surpreendidos sentados em círculo no chão, fracionando e embalando cocaína. Já havia 8 porções embaladas e outra a granel. Encontraram também balança de precisão e embalagens plásticas. Localizadas mais 25 porções de crack no mesmo cômodo, já embaladas e prontas para venda. Na carteira de Higor foi encontrado R\$110,00, e de Marcos R\$200,00. Os três réus estavam embalando e preparando as drogas. A cocaína estava em um prato de plástico, com uma colher. Havia denúncia de que Higor praticava tráfico de drogas no local. O réu Marcos não era conhecido da polícia, contudo, Higor já tinha passagem por tráfico. Não sabiam que João Vitor estaria na residência. Disse que João Vitor estava com um saco plástico na mão e auxiliando na embalagem. Não sabe se havia resquício de entorpecentes na mão do João.

A testemunha JOSÉ LUIS JUNQUEIRA A. FILHO, delegado de polícia, em seu depoimento judicial, relatou que no final do mês de setembro de 2021 receberam informações acerca de que no local do fato (residência de Higor) estaria ocorrendo a venda de drogas. O investigador Claudinei realizou relatório preliminar e verificou movimentação suspeita. Dias depois chegaram novas informações sobre venda de drogas no local. Em razão disso, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, sendo deferido. O réu Higor já era conhecido da polícia, e já foi preso por tráfico de drogas. No início de outubro de 2021, resolveram dar cumprimento ao mandado. Do lado de fora ouviram uma música no interior da casa. Uma porta dos fundos estava totalmente aberta e, quando entrou, conseguiu ver os três réus sentados no chão do quarto. Deu voz de abordagem e verificou que ao centro da roda havia um prato plástico com uma colher e uma porção a granel de cocaína, bem como algumas porções já embaladas espalhadas pelo chão. Os três estavam embalando as drogas. Um auxiliando ao outro colocando as drogas na embalagem. João Vitor estava com saco plástico na mão. Já havia 8 porções de cocaína fracionadas e sendo embaladas. Havia também balança de precisão e sacos plásticos para embalagem. Encontraram também 25 porções de crack já embaladas. Na carteira de Higor continha R\$110,00 e de Marcos R\$200,00. O que chamou atenção foi a forma organizada em que agiam. Em outras investigações não se davam conta acerca da participação do réu Marcos. No dia não havia ninguém comprando drogas.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente os réus. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu Higor de Mattos Fernandes confessou os fatos. Disse que é usuário de drogas. Asseverou que estavam usando a droga encontrada no prato (cocaína). As drogas estavam guardadas para não usarem tudo de uma vez. Com relação às 25 porções de crack, alegou que estava guardando para outro traficante chamado "neguinho" de Osvaldo Cruz. Os outros réus não sabiam que Higor guardava droga para traficante.

Interrogado judicialmente, o réu Marcos André da Silva dos Santos negou os fatos. Disse que estava no quarto, mas não estava embalando droga. Estava apenas usando cocaína que estava no prato. Não viu as porções de crack. Não sabia que Higor traficava drogas. Não sabia que Higor estava guardando drogas para outro traficante. Disse que é usuário de cocaína.

Interrogado judicialmente, o réu João Vitor Gonçalves da Silva negou os fatos. Disse que tinha passado na casa do Higor, pois iria oferecer um emprego a ele. Estava no quarto conversando com os réus, sendo que neste momento a polícia chegou. Viu Higor e Marcos embalando drogas que estavam no prato, mas não viu as demais porções de crack.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, a autoria delitiva é certa.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente (9

porções de cocaína - 9.2 gramas, e 25 porções de crack - 17.8 gramas); os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; além de ter sido encontrado no local uma balança digital. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação aos réus. A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante, comprova a mercancia perpetrada pelos réus. Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendidas (cocaína e crack) constam no rol. Portanto, se enquadram no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O réu Higor confessou que as porções de crack eram de propriedade de outro traficante, contudo, estava realizando a guarda das drogas.

Os réus Marcos e João negaram totalmente a prática delitiva, contudo, João disse ter visto Higor e Marcos embalando as drogas que estavam no prato.

Não obstante, estas negativas destoam do conjunto probatório. A narrativa não encontra amparo nas demais provas produzidas. Os depoimentos das testemunhas, coerentes e harmônicos entre si, deixam isolada a versão dos réus, que, por isso, não são suficientes para a absolvição.

Os réus foram surpreendidos pelos policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Higor, fracionando e embalando as drogas.

Ademais, outras porções de crack já estavam preparadas para a venda, além de haver no local uma balança de precisão e embalagens plásticas para guarda da droga.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e unânime conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram o crime de tráfico de drogas.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, a autoria não resta-se comprovada.

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

No caso em tela verifico que não havia investigação em curso acerca da associação dos réus, mas apenas quanto ao local que seria ponto de venda de drogas. Contudo, os réus foram presos em flagrante preparando drogas para a venda.

O depoimento dos policiais e o interrogatório dos réus foram nesse sentido.

Para a consumação do crime do art. 35, da Lei de Drogas, é imprescindível que haja o animus associativo, o que não aconteceu. No caso em tela, houve uma reunião eventual, configurando apenas concurso de pessoas.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR: 00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018.

Portanto, resta-se não comprovada a estabilidade e permanência da associação. Razão pela qual, com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, a acusação é improcedente.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal. Destarte, a prova colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

RÉU HIGOR DE MATTOS FERNANDES:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0003316-08.2016.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/09/2019 - fl. 241). Outrossim, foram apreendidas 9 porções de cocaína, totalizando 9.2 gramas, e 25 porções de crack, totalizando 17.8 gramas, conforme auto de apreensão de fls. 12/13, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem ao aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, aumento em 1/3, e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0000277-30.2016.8.26.0592, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/02/2018 - fl. 240). Ademais, o réu confessou a prática criminosa, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.

Compulsando os autos (fls. 64/68), verifico que o réu possui três condenações com trânsito em julgado, sendo que uma já foi utilizada na primeira fase da dosimetria: processo nº 0003316-08.2016.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/09/2019; processo nº 0000277-30.2016.8.26.0592, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/02/2018; processo nº 0001428-28.2021.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/07/2021). Portanto, o réu é multirreincidente.

Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 488709 SP 2019/0006279-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019; STJ - HC: 406422 ES 2017/0159888-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - APR: 01058725820178260050 SP 0105872-58.2017.8.26.0050, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 27/03/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2019; TJ-SP - APR: 00634027520188260050 SP 0063402-75.2018.8.26.0050, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021), a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, contudo, haja vista o réu ser multirreincidente, não há que se

falar em compensação integral, mas sim em aumento da reprimenda na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a aplicação da agravante da reincidência. Conforme precedentes do E. TJSP deve haver a compensação parcial. Vejamos: APR: 15001351120208260236 SP 1500135-11.2020.8.26.0236, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 20/10/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2020; APR: 15004005620198260621 SP 1500400-56.2019.8.26.0621, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 03/11/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020; APR: 00072410620188260451 SP 0007241-06.2018.8.26.0451, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 16/02/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2021. Destarte, aumento em 1/8 e fixo a pena provisória em 07 anos e 06 meses de reclusão, e 749 dias-multa. Terceira fase: Não há majorantes ou minorantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada. Fixo o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu. O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista ser reincidente.

RÉU MARCOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS:

Primeira fase: Foram apreendidas 9 porções de cocaína, totalizando 9.2 gramas, e 25 porções de crack, totalizando 17.8 gramas, conforme auto de apreensão de fls. 12/13, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem ao aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Destarte, aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Segunda fase: Há incidência da atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, posto que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. Razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e fixo a pena provisória em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa. Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3. O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Contudo, como a quantidade e a natureza da droga apreendida foram utilizadas para exasperar a pena-base, e para evitar o bis in idem, deixo de utilizar o art. 42 da Lei de regências neste momento (TJ-SP - APR: 00048820820178260358 SP 0004882-08.2017.8.26.0358, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 09/06/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020; STJ - HC: 356681 MS 2016/0129533-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016). Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/4, fixando a pena definitiva em 03 anos e 09 meses de reclusão, e 375 dias-multa.

Fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista o quantum de pena aplicada.

CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que o condenado preenche os requisitos legais. Portanto, consoante artigo 44, § 2º, segunda parte, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana a serem especificadas pelo juízo da execução penal. Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

resta prejudicada a análise da suspensão do artigo 77, CP.

RÉU JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA:

Primeira fase: Foram apreendidas 9 porções de cocaína, totalizando 9.2 gramas, e 25 porções de crack, totalizando 17.8 gramas, conforme auto de apreensão de fls.

12/13, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem ao aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Destarte, aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Contudo, como a quantidade e a natureza da droga apreendida foram utilizadas para exasperar a pena-base, e para evitar o bis in idem, deixo de utilizar o art. 42 da Lei de regências neste momento (TJ-SP - APR: 00048820820178260358 SP 0004882-08.2017.8.26.0358, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 09/06/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020; STJ - HC: 356681 MS 2016/0129533-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016). Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/4, fixando a pena definitiva em 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, e 437 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista o quantum de pena aplicada.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista o quantum de pena aplicada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR HIGOR DE MATTOS FERNANDES como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 07 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e 749 dias-multa;

CONDENAR MARCOS ANDRÉ DA SILVA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 03 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida

em regime inicialmente aberto, e 375 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade nos termos acima fixados;
CONDENAR JOÃO VITOR GONÇALVES DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 437 dias-multa;
ABSOLVER todos os réus do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Deixo de decretar a prisão preventiva do réu MARCOS e do réu JOÃO VITOR, haja vista o habeas corpus concedido pelo STJ (168/173), bem como o regime inicialmente fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tornam incompatível a segregação cautelar.

Por sua vez, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU HIGOR DE MATTOS FERNANDES, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O acusado possui longa folha de antecedentes (fls. 240/244), além de ser reincidente específico em tráfico de drogas. O que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública.

Com efeito, o crime de tráfico, é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitiva, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E.

Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP, em proporção.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie, se for o caso.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 21 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA